

1500860-73.2022.8.26.0577

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Loureiro Sobrinho

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... em depósito".

O fim específico de tráfico não é elemento subjetivo do tipo, o qual não prevê dolo específico, decorrendo da subsunção da conduta a um dos verbos descritos nele. O tráfico está assim caracterizado, devendo-se comprovar o elemento específico apenas nos casos do artigo 28, da Lei 11.343/06, ou seja, o uso próprio.

Mas, mesmo se assim não fosse, o fim de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

1ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500860-73.2022.8.26.0577 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500860-73.2022.8.26.0577

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2050184/2022 - 2ª ENTORPECENTES-

DEIC-DEINTER 1, 23161978 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 1, 9/22/552 -

2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 1, 2050184 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 1

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCO ANTONIO DA CONCEIÇÃO JUNIOR e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Loureiro Sobrinho

Vistos.

1. MARCO ANTONIO DA CONCEIÇÃO JUNIOR, CHRISTOPHER JONATHAN DOS SANTOS, LUCAS MARQUES DA SILVA e DANIEL ALVES DE OLIVEIRA SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", e artigo 35, "caput", c.c. o artigo 40, VI, todos da Lei 11.343/06, porque na data e local descritos na denúncia, agindo com consciência e vontade livres, em concurso de agentes e unidade de desígnios com o adolescente L.R.C.C., após associaram-se para o fim de cometerem tráfico ilícito, de forma reiterada ou não, respectivamente, traziam consigo, transportavam, tinham em depósito e guardavam, substâncias entorpecentes, a saber,

05 porções de maconha, 598 cápsulas de cocaína, 01 porção maior de cocaína, 15 porções médias de maconha, 26 porções de maconha, 618 porções de maconha e 93 porções de skunk, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Os réus foram notificados.

Defesa prévia foi apresentada.

A denúncia foi recebida.

Os réus foram citados e, em audiência de instrução debates e julgamento, realizada por videoconferência pelo sistema teams, foram ouvidas testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, procedendo-se, enfim, ao interrogatório dos réus.

Em memoriais, o representante do Ministério Público pleiteou a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, com a consequente condenação dos réus. A defesa, preliminarmente, requereu a nulidade do feito, tendo em vista violação de domicílio, bem como a ilicitude da prova pois derivada e produzida em razão da prática de tortura. No mérito, pugnou pela absolvição, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal, reconhecendo-se a atenuante da confissão espontânea, com redução máxima prevista na Lei de Drogas, substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, estabelecimento da multa nos moldes do Código Penal, e concessão do direito de recorrer em liberdade, restituindo-se o veículo apreendido. É o relatório.

DECIDO.

2.As preliminares se confundem com o mérito e com ele será analisada.

No mérito, a ação penal deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade do delito de tráfico está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico de fls., que apontou resultado positivo para maconha e cocaína, não merecendo reparo, pois bem se utilizou da boa técnica existente.

A autoria é indubitosa.

O réu Christopher, em seu interrogatório, disse que a droga estava em seu poder, a qual depositava para terceiro, mas não para fins de tráfico, recebendo, contudo, dinheiro para isso, pois passava por necessidades financeiras. Destacou que os corréus sequer sabiam da presença da droga em sua casa, pois lá apenas estavam como amigo (Lucas), senhorio (Marco Antonio), sendo um dos corréus (Daniel) um desconhecido.

Já os demais corréus, interrogados, negaram a acusação. Disseram que estavam na casa, no caso de Marco Antonio na situação de senhorio, enquanto Lucas na condição de amigo de Christopher. Destacaram que presenciaram a diligência policial em questão e o encontro da droga em uma mochila na posse de Christopher, droga essa que não lhes pertenciam, sequer sabendo da existência. Já o réu Daniel asseverou que somente passava pelo local a bordo de sua moto, sendo abordado pelos policiais, mesmo não tendo nada de ilícito em seu poder. Enfim, os policiais apresentaram a droga em tela que injustamente lhe imputaram.

Tais versões, contudo, não podem ser levadas em conta, pois inconsistentes e incoerentes, não encontrando respaldo no isento conjunto probatório, destacando-se, desde já que a parcial confissão do réu Christopher não lhe aproveitará como atenuante, pois indigna de crédito, uma vez que notadamente quis ele beneficiar os demais, tentando isentá-los de condenação, possivelmente em virtude da específica reincidência de um deles.

A prova oral, por sua vez, corroborou, em parte, os fatos descritos na denúncia. As testemunhas ouvidas, policiais civis, de maneira firme e coerente, informaram que havia denúncia anônima dando conta de que no local dos fatos, espécie de "garagem" ou "casa bomba", havia droga armazenada para destruição em biqueiras para fins de tráfico. Assim, para lá se dirigiram estabelecendo campana, percebendo uma motocicleta, que já constava na denúncia, aproximar-se e um indivíduo dela descer entrar na casa e retornar. Então, foi este indivíduo abordado, constatando-se ser o réu Daniel, havendo com ele porções de maconha, acondicionada em espécie de dinamite, típica para abastecimento de biqueiras em maior quantidade. Prosseguindo, foi o réu Marco Antonio abordado, franqueando este a entrada na casa, onde estavam os demais corréus e o menor L., tentando alguns deles fugir, mas, contudo, foram

detidos. Já na residência havia a droga em questão, bem como balança de precisão, kit para o preparo de drogas e R\$ 200,00. Indagados, os réus confessaram que atuavam conjuntamente para fins de tráfico, em ação coordenada, com divisão de trabalho, armazenando e preparando as drogas, visando abastecimento de biqueira existe nas proximidades. Enfim, foram todos conduzidos presos à Delegacia de Polícia.

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, terem os réus realizado o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, em suas elementares, na forma descrita na denúncia.

O conceito de suficiência, não se confunde, para efeito de condenação, com isenção total de eiva indubitativa, consiste, pois, na firme possibilidade de afirmação da realidade do fato imputado e de definição de sua autoria, no contexto das comprimidas fronteiras humanas da capacidade de apreensão dos elementos probatórios e de reconstituição do episódio delituoso. Prova suficiente não é nem pode ser penhor de certeza plena, de que somente os deuses são senhores. Daí se afigura irreal e meramente retórico o emprego de expressões como "prova categórica", "prova cabal", e outras do gênero.

Bem assim, há prova suficiente de que a substância entorpecente foi encontrada em poder dos réus, o que, por si só, autoriza a condenação.

Autoriza porque, desta forma, os réus praticaram a conduta típica prevista no artigo 33, da Lei 11.343/06, incidindo em pelo menos dois dos verbos descritos na figura típica, quais sejam, "trazer consigo" e "ter em depósito".

O fim específico de tráfico não é elemento subjetivo do tipo, o qual não prevê dolo específico, decorrendo da subsunção da conduta a um dos verbos descritos nele. O tráfico está assim caracterizado, devendo-se comprovar o elemento específico apenas nos casos do artigo 28, da Lei 11.343/06, ou seja, o uso próprio.

Mas, mesmo se assim não fosse, o fim de mercancia ilícita está demonstrado ante as peculiaridades do caso, ou melhor, a considerável quantidade, diversidade e a forma em que o entorpecente estava separado e acondicionado, o encontro de petrechos relacionados ao tráfico, tais como balanças de precisão, dinheiro, e a confissão informal de que faziam do tráfico seu meio de vida, atuando em ação coordenada, com divisão de trabalho para armazenar, preparar drogas e abastecer biqueiras, isso sem dizer da denúncia anônima, apontam para fins de comercialização, para repasse a terceiros.

O fato da substância entorpecente ter sido encontrada em poder dos réus, inverte o ônus da prova, impondo-lhe justificativa verossímil, fazendo incidir sobre ela presunção de culpabilidade.

No caso presente, os réus não fizeram prova suficiente nesse sentido, pois se invertendo o ônus da prova, a suficiência probatória, agora para afastar ou, pelo menos, estabelecer a dúvida sobre a acusação, compete a eles.

Não se diga que o testemunho de policiais deva ser recebido com reservas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. Pelo contrário, o testemunho de policiais deve merecer credibilidade, pois não faz sentido que eles, credenciados pelo Estado para atuarem na repressão e na prevenção delitiva, sejam desconsiderados, quando compromissados, como qualquer outra testemunha, que vêm a juízo relatar diligências a que procederam no exercício de suas funções.

Neste ponto, bom salientar que a palavra dos policiais prepondera sobre as assertivas do réu, pois não é crível que o réu, flagrados em pleno porte de droga, apontando o local onde estaria mais entorpecente, não tivesse franqueado a entrada e mostrado onde o entorpecente jazia, não sendo crível também que em tais circunstâncias tivesse ocorrido tortura, a qual se não pode basear apenas nas parciais palavras dos réus, ainda mais quando há justificativa razoável para sua ocorrência por parte dos agentes de autoridade. Assim, cai por terra qualquer alegação de violação de domicílio ou de tortura, não sendo demais lembrar que por ser o delito de tráfico de natureza permanente, prescinde de mandado ou de autorização de qualquer morador para se realizar a diligência e consumir o flagrante, sem embargo das opiniões em contrário.

Quanto à co-autoria, frise-se que, nos termos do artigo 29, "caput", do Código Penal, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este

cominada, na medida de sua culpabilidade.

"Co-autoria 'é a realização conjunta de um delito por várias pessoas que colaboram consciente e voluntariamente' (Muñoz Conde, Teoría General del Delito, 1984, pg. 292). Cada co-autor é um autor e, por isso, deve apresentar as características próprias do autor. Isto significa que o co-autor 'é aquele autor que tem o domínio da realização do fato conjuntamente com outro ou outros autores, com os quais tem um plano comum e uma distribuições de funções na realização do mútuo acordo' (Juan Bustos Ramirez, Manual de Derecho Penal Español, 1984, pg. 331)".

"A co-autoria é nada mais nada menos, em última análise, a própria autoria. Funda-se ela sobre o princípio da divisão do trabalho; cada autor colabora com sua parte no fato, a parte dos demais, na totalidade do delito e, por isso, responde pelo todo. Há na co-autoria, a decisão comum para a realização do resultado e a execução da conduta".

Diante do conjunto probatório, tudo leva a crer que os corréus são co-autores, porque, de qualquer modo, contribuíram para o crime, estando previamente associados entre si e com unidade de propósitos, tendo o domínio final do fato típico, o qual praticaram, não podendo ser considerados como meros partícipes, vez que nenhum deles simplesmente apenas contribuiu auxiliando a conduta do outro.

Por outro lado, comprovado não está o delito previsto no artigo 35, "caput", da Lei 11343/06.

Não é o simples concurso de pessoas que caracteriza associação. Necessário é o "animus" associativo prévio, sem dúvida uma "societas sceleris". Necessária é a comprovação de tal elemento do tipo, ou seja, vínculo associativo de caráter permanente, duradouro, que se depreende de vários elementos tais como reuniões prévias, base de operação, níveis de lucros presumidos, etc., o que não corre nos autos.

Ainda, clara está a tipicidade da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/06, ressaltando-se, ante o conjunto probatório, não haver dúvida que o tráfico de entorpecente em questão envolvia o adolescente L., coautor no delito, tanto que encontrado e preso no momento da abordagem policial, tendo em vista precisa e específica indicação do réu.

De outra banda, em razão das peculiaridades do caso, tudo leva a crer que o dinheiro encontrado era produto do ilícito, não se logrando provar o contrário, ou seja, sua origem lícita, sendo de rigor seu perdimento a favor da União, como efeito da condenação, nos termos do artigo 91, II, "b", do Código Penal.

Destarte, comprovadas a materialidade e a autoria pelo delito de tráfico ilegal de drogas, impõe-se a condenação e por insuficiência probatória se impõe a absolvição quanto ao crime de associação para tal fim.

Na aplicação da pena, sopesadas as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, as penas-base devem ser fixadas no mínimo legal.

Na aplicação da pena, sopesadas as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, as penas-base devem ser fixadas no mínimo legal, não se aplicando a redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois há prova bastante de se dedicarem os réus a atividades criminosas, tendo em vista o encontro de razoável quantidade de droga e de balanças de precisão, bem como da própria confissão informal dos réus de que estariam a realizar o tráfico ilícito em ação coordenada, com divisão de tarefas, fornecendo a terceiros a droga a granel, para que eles abastecerem biqueiras, demonstrando-se de forma clara que estavam a fazer do odioso tráfico de drogas seus meios de vidas.

Prosseguindo, deve haver aumento, em um sexto, tendo em vista a causa especial de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/06.

Essa pena, assim, deve ser tornada definitiva, na ausência de outras condições modificadoras.

Em razão das condições econômicas dos réus, a unidade do dia multa deve ser fixada no mínimo legal, devendo ser aplicado, neste ponto, o previsto na Lei 11.343/06, em razão do princípio da especialidade.

3. Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e

ABSOLVO os réus MARCO ANTONIO DA CONCEIÇÃO JUNIOR, CHRISTOPHER JONATHAN DOS SANTOS,

LUCAS MARQUES DA SILVA e DANIEL ALVES DE OLIVEIRA SANTOS, qualificados nos atos, da imputação a eles feita na denúncia pela infração penal prevista no artigo 35, da Lei 11.343/06, e o faço por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal;

CONDENO os réus MARCO ANTONIO DA CONCEIÇÃO JUNIOR, CHRISTOPHER JONATHAN DOS SANTOS, LUCAS MARQUES DA SILVA e DANIEL ALVES DE OLIVEIRA SANTOS, qualificados nos autos, como incurso 33, "caput", c.c. o artigo 40, VI, ambos da Lei 11.343/06 da Lei 11.343/06 à pena de cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, com unidade fixada no mínimo legal.

Não fazem os réus jus ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, do Código Penal, pois o crime de tráfico de drogas é grave, equiparado inclusive ao hediondo. Ainda, o delito em questão está capitulado em Lei Especial (nº 11.343/06), e tal, em seu artigo 33, § 4º, veda expressamente o aludido benefício, o qual nada tem de inconstitucional, pois apenas atende ao princípio de individualização da pena, observando a gravidade intrínseca do crime em questão. Mesmo se isso não bastasse, no caso, a quantidade de pena imposta impede este direito subjetivo ao réu.

Pelos mesmos motivos, o regime inicial para cumprimento das penas deverá ser o fechado, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal e artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, com a nova redação que lhe foi dada, mas notada e precipuamente, porque assim recomendam os elementos concretos e individualizados, ante a gravidade do tráfico em questão, que na situação concreta, não provém de simples abstrações, suposições ou meras presunções, mas, sim, da situação fática descrita na denúncia, consistente na apreensão de considerável quantidade de droga diversa, acondicionada em diversos tijolos, droga essa destinada ao abastecimento de biqueiras, o que não só põe em relevo a periculosidade dos agentes, como também justifica e autoriza regime inicial mais gravoso.

Também pelos mesmos motivos, não têm os réus o direito de apelar em liberdade, tendo em vista estarem presentes os requisitos da custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública, ante a gravidade do delito em questão, tráfico ilícito de cocaína e maconha, inclusive em sua forma mais lesiva, com alta concentração e maior capacidade alucinógena, denominada "skunk", acondicionadas em diversos invólucros, envolvendo pessoa de menor idade, fazendo do tráfico seu meio de vida, abastecendo ponto de venda de drogas, de nefastas consequências para a sociedade, a qual, assim, deve ser preservada.

Determino, ainda, o perdimento, a favor da União, do dinheiro apreendido, nos termos do artigo 91, II, "b", do Código Penal, devendo-se ser entregue ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, procedendo-se nos termos do artigo 60 e seguintes, da Lei 11.343/06.

P.R.I.C.

São José dos Campos, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA